

1509967-24.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509967-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509967-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114539/2022 - 91º D.P. CEASA, 24587282 - 91º D.P. CEASA, 2114539 - 91º D.P. CEASA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONAS TIAGO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JONAS TIAGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Isso porque, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 20h40, na Rua Capitão Francisco Teixeira Nogueira, altura do número 100, Barra Funda, nesta cidade e Comarca, o acusado, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: a) 259,3g de maconha, fracionadas em 61 invólucros; b) 10g de crack, acondicionadas em 159 invólucros; e c) 95,1g de cocaína em pó, acondicionadas em 231 invólucros, substâncias entorpecentes que causam dependência química e física. Narra a denúncia que o acusado, com vontade livre e consciente, trazia consigo,

para fins de tráfico, porções de maconha, cocaína e crack, embaladas individualmente, prontas para o comércio.

Policiais Militares realizavam patrulhamento no local quando, durante incursão a pé na comunidade ali instalada, avistaram o acusado, que ao notar suas presenças dispensou uma pequena bolsa que trazia em poder e correu em fuga. JONAS foi alcançado e detido e a bolsa por ele dispensada foi recuperada. Em busca pessoal nada foi localizado com o denunciado, no entanto, na bolsinha que ele dispensou estavam as porções de entorpecentes, individualmente embaladas, prontas para o comércio. Informalmente, o acusado confessou que estava no local praticando o tráfico, mas formalmente interrogada, optou por silêncio.

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, foi ela recebida por despacho no dia 16 de agosto de 2022 (fls. 79/82). Consequentemente, o acusado foi citado (fls. 121), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 78). Inviável a absolvição sumária, designei audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro de 2022 (fls. 79/82).

Durante a instrução de causa foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o acusado interrogado ao final da instrução, tudo registrado em mídias digitais acostadas ao autos.

Encerrada a instrução criminal, Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia mas não se opôs a concessão do benefício.

A defesa requereu a absolvição mas, em caso de condenação, requereu a concessão do benefício com carga redutora máxima, regime aberto, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 22/24); o auto de prisão em flagrante (fls. 04); o auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); o laudos periciais da substância entorpecente, (fls. 27/30; 67/69); bem como as folhas de antecedentes do acusado (fls. 33/35; 61/62).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e dos laudos de constatação provisória (fls. 27/30), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 67/69), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva.

Em juízo, o policial Ricardo reconheceu o acusado de uma ocorrência de tráfico de drogas. Estava em patrulhamento na zona oeste, ao lado do CT do São paulo e em uma comunidade, ali ao lado, fez um incursão no local a pé. No local, viu o acusado que estava com uma bolsinha e ao perceber a presença da polícia jogou a bolsa no chão, fingiu tropeçar. Dentro da bolsinha localizou cocaína, crack e maconha. Todo o entorpecente se encontrava dentro de saquinho, todos prontos para venda. Acredita que os fatos ocorreram a noite, pelo que se recorda, madrugada. Viu o acusado jogando a pochete no chão. O nome de guerra do policial que estava com a testemunha é Riscala que a tudo presenciou e foi ele quem aprendeu a bolsa. O acusado reconheceu que estava iniciando a venda de drogas naquele momento. A comunidade é grande e conhecida do declarante. Ele estava sozinho quando foi visto pela equipe. João Vítor, o outro policial, também reconheceu o acusado de tráfico de drogas. Estava em patrulhamento ostensivo e entraram, a pé, na comunidade Água Branca. Assim que entrou, viu Jonas com algo nas mãos. Quando ele percebeu a presença policial, ele começou a correr mas já conseguiu segurá-lo. Ele estava muito próximo. Visualizou quando ele dispensou o volume que carregava nas mãos. Era uma bolsinha preta. Foi o depoente quem localizou a bolsinha e dentro vários entorpecentes, já fracionados para venda. Viu que depois da perícia eram três tipos

de entorpecentes. Ele não ofereceu resistência. Ele nada falou sobre os fatos. Ele estava sozinho. Os fatos ocorreram a noite, mas havia luz artificial. Em determinado momento se separou do outro policial para retirar alguns materiais do guarda preso, mochilas e outras itens para que então o réu fosse colocado no interior da viatura.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos a confissão do acusado obtida em juízo, vejamos.

Jonas declarou que tem 33 anos de idade, solteiro, tem filhos. Trabalha com prestação de serviços, carga e descagar, para Leo madeiras. Na época dos fatos estava desempregado. Nunca foi processado anteriormente. Reconhece que estava com o entorpecente porque estava desesperado. Foi a primeira vez que foi praticar o crime e acabou sendo preso. Admite que o entorpecente apreendido estava com ele e seria destinado a venda. Reconhece que soltou a pochete no chão. Mora com os pais. Antes também morava com eles. Pretende retornar aos estudos e dar o melhor para seus filhos.

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, a confissão não será utilizada para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, nos termos do que propugnados pelo Ministério Público com a qual a Defesa, em tese subsidiária concordou, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui Maus antecedentes, fls. 61/62 e 64. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou

portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno JONAS TIAGO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão, REGIME ABERTO, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato. Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal. O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal.

Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Isento de custas.

Publicada em audiência.

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA